

1502152-74.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Joice Sofiati Salgado

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIS HENRIQUE FIORAVANTE

Vistos,

I. Relatório.

LUIS HENRIQUE FIORAVANTE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12 da Lei 10.826/03, ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis[Foro do Processo]

2ª Vara

Praça Doutor Mário Lins, s/nº, Jardinópolis - SP - cep 14680-000

1502152-74.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502152-74.2021.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIS HENRIQUE FIORAVANTE

Vistos,

I. Relatório.

LUIS HENRIQUE FIORAVANTE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12 da Lei 10.826/03, ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, porque, no dia, horário e local indicados na denúncia, durante período de calamidade pública, teria trazido consigo e guardado, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 50,35g (cinquenta gramas e trinta e cinco centígramas) de substância entorpecente TETRAHIDROCANNABINOL (THC), acondicionada em 38 (trinta e oito) invólucros de plástico do tipo "filme" retorcido, encerrando porções de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos; 22,5g (vinte e duas gramas e trinta e cinquenta

centigramas) da substância entorpecente TETRAHIDROCANNABINOL (THC), acondicionada em um invólucro de plástico do tipo "filme" retorcido encerrando porções de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos; 1,8g (um grama e oitenta centigramas) da substância entorpecente TETRAHIDROCANNABINOL (THC), acondicionada em um invólucro de plástico do tipo "filme" retorcido encerrando porções de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos; 3,83g (três gramas e oitenta e três centigramas) da substância entorpecente cocaína, acondicionada em 08 (oito) microtubos plásticos do tipo "eppendorf" incolores e de tamanho pequeno (0,5 ml), dotado de tampa própria, encerrando porção de material sólido particulado esbranquiçado (cf. aditamento da denúncia); e, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos, durante período de calamidade pública, teria possuído e mantido sob sua guarda, no interior de sua residência, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar (fls.145/152).

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022 (fls.153/154).

O acusado foi citado à fls. 168.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu.

Nas alegações finais, a representante do Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio, e, quanto ao delito previsto na Lei de Drogas, a absolvição e, subsidiariamente, a concessão de benefícios legais.

É o relatório.

II. Fundamentação.

A pretensão punitiva estatal é procedente, em parte.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/06), boletim de ocorrência (fls.11/13), auto de exibição e apreensão (fls.14/15), laudo de exame químico toxicológico (fls. 88/90), laudo pericial (fls.91/94), bem como pela prova oral produzida.

Passo a análise da autoria dos crimes.

O acusado, perante autoridade policial, informou que o entorpecente localizado na residência era de sua propriedade e seria utilizado para consumo próprio. Relatou que o dinheiro apreendido era proveniente de sua atividade laboral como carregador na "CEAGESP". Declarou que a munição foi encontrada na rua. Por fim, negou realizar o tráfico de entorpecentes (fls.09). Em juízo, afirmou ser usuário de drogas e nunca ter feito tratamento para o vício. Disse que a droga apreendida era de sua propriedade e destinada ao consumo próprio. Alegou ter adquirido tal quantidade para evitar de ir em biqueiras e comprou com dinheiro proveniente da venda de um celular. Adquiriu o estupefaciente na cidade de Ribeirão Preto. Aduziu que a quantia apreendida era parte do valor obtido com a venda do telefone, que deixou guardada junto com a droga. Negou a prática do tráfico. Quanto a munição, alegou ter ganho de um amigo, "Coloquinha", e pretendia fazer um chaveiro.

O policial militar Washington de Souza, em fase extrajudicial, relatou que faziam o patrulhamento pelo bairro Vila Paulista, quando, ao abrir o portão da residência e visualizar a Polícia Militar, o acusado jogou uma porção de maconha ao solo. Aduziu que fizeram a abordagem do réu, que morava no local, e estava muito nervoso.

Salientou que avistaram uma munição de calibre 12 na janela e, ao ser indagado, inicialmente, o réu falou que havia achado essa munição e, posteriormente, disse ter ganhado de "Coloquinha". Asseverou que a avó e o irmão do acusado estavam presentes no local, franquearam a entrada dos policiais na residência e acompanharam as vistorias no local. Mencionou que foi localizada uma sacola plástica, "maconha", microtubos de cocaínas e a quantia de R\$219,10 (duzentos e dezenove reais e dez centavos) em cima de um "rack". Esclareceu que, além disso, foi localizada a quantia de R\$25,00 (vinte e cinco) reais na varanda da residência (fls.07). Em juízo, disse que estavam em patrulhamento e, defronte a residência do réu, se depararam com dois indivíduos que agiram de forma dissimulada, tentando deixar o local; então, realizaram abordagem e, na ocasião, o réu abriu portão e ao vê-los, dispensou um porção de maconha; então, enquanto falava com ele, ele deixou portão aberto, de modo que avistou uma munição na janela. Em seguida o irmão e a avó do acusado compareceram no local e franquearam a entrada na residência; na garagem, no chão, localizaram uma quantia em dinheiro; na sala, em uma cômoda, localizaram porções de maconha, cápsulas de de cocaína; embalagens de plástico, usadas para embalar droga. Disse que o réu afirmou ter comprado a droga no bairro Vila Carvalho, na cidade de Ribeirão Preto, e iria vender. No interior da casa, encontraram uma quantia em dinheiro, aproximadamente R\$ 300,00, cuja procedência ele não informou. Disse que o dinheiro estava na cômoda, junto com o entorpecente. Quanto a munição, o réu disse que ganhou de vulgo "Coloquinha". Afirmou que não o conhecia o acusado e explicou que ele só foi abordado porque saiu da residência e dispensou a droga. Narrou que os indivíduos nada falaram sobre ir ao local para comprar droga.

O policial militar Gilberto Ferreira Reis, em juízo, afirmou que foi seu colega quem viu o réu dispensar o entorpecente e avistou a munição na janela. Disse que ele assumiu a propriedade da droga e teria comprado em Ribeirão Preto, mas não lembrou da versão do acusado sobre o destino do estupefaciente, já que foi seu colega quem conversou com ele. Quanto a munição, o réu disse ter ganho de "Coloquinha".

Eis o teor da prova oral.

Em relação ao delito do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Analisando-se a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, tem-se que o quadro probatório, de modo algum beneficia o acusado, não tendo sua versão sido comprovada, conforme ônus que competia à defesa.

Com efeito, apesar do alegado destino para uso próprio da droga, não é o que se infere da prova produzida.

A grande quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas e a localização de embalagem plástica e de dinheiro sem comprovação de origem lícita junto ao estupefaciente demonstram, à saciedade, que as drogas, ainda que em parte, se destinavam ao consumo de terceiros.

Aliás, nesse ponto, não explicou o réu porque guardava seu dinheiro junto com os entorpecentes. Ainda, não comprovou exercer atividade lícita e tampouco a procedência da quantia apreendida.

Não se descarta que o réu possa usar drogas, mas o fato do acusado ser usuário de drogas também não é suficiente para afastar o crime, pois tem se tornado cada vez mais comum situações em que o usuário pratica o tráfico para sustentar o próprio vício.

Além disso, há a confissão informal realizada ao policial militar.

Ora, não há nos autos qualquer indício de que o policial tenha agido de forma

abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do acusado. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta do policial, que sequer conhecia o réu.

Embora os policiais não tenham visto o réu entregando drogas a terceiros na data da apreensão, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como núcleos "(...) ter em depósito, (...), guardar (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente mantenha em depósito ou guarde o entorpecente - o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Logo, patente a autoria do crime.

Em relação ao delito do artigo 12 da Lei 10.826/03.

Evidente da autoria do crime, já que a confissão do réu foi corroborada pelos firmes depoimentos dos policiais militares.

A partir desses indícios e da ausência de qualquer outro contra-indício por parte do acusado, de rigor a sua condenação, anotando que o crime contido no artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/03 refere-se àqueles denominados pela doutrina como de perigo abstrato. Para sua consumação basta a realização de uma das ações nucleares do tipo penal em tela, sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; qualquer avaliação subsequente para ocorrência de efetivo perigo à coletividade revela-se irrelevante.

E, neste ponto, não merece acolhida a tese da Defesa, pois o crime em análise se consuma com a posse da munição na residência, sem autorização para tanto, não se exigindo dolo específico, sendo, pois, irrelevante a intenção do agente.

Por outro lado, alterando entendimento anteriormente adotado, não se vislumbra mais hipótese de reconhecimento da agravante da calamidade pública. Isso porque não há fato no caso em apreço que demonstre que a ré tenha se aproveitado da situação imposta pela pandemia do novo coronavírus para o cometimento dos crimes em tela.

Nesse sentido:

"[...]

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021);

"Tráfico de drogas - mantidas as condenações - circunstâncias que denotam ciência dos acusados de que no veículo havia mais de nove quilogramas de maconha. Afastamento da preliminar de nulidade decorrente da ausência de resposta à acusação - a Defesa foi regularmente intimada para apresentar a defesa preliminar, não o fazendo - nova oportunidade foi aberta durante a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas contidas no rol do parquet, sem qualquer insurgência. Redução das básicas - possibilidade - "reprovação social" por "passagem pela Justiça", sem apontar eventual certidão de condenação definitiva. Afastamento da agravante relativa ao crime cometido durante estado de calamidade pública - Possibilidade - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito. Manutenção do regime prisional fechado - réus reincidentes - penas que excedem o quadriênio. Recursos parcialmente providos." (TJSP; Apelação Criminal 1513057-74.2021.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

Por fim, não é caso do reconhecimento de concurso formal de delitos, como pretendido pela Defesa, vez que, na hipótese, o réu praticou mais de uma conduta, incidindo-se, pois, o previsto no artigo 69 do Código Penal.

Destarte, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Quanto ao crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que se trata de réu que não ostenta maus antecedentes.

Com efeito, a condenação no artigo 28 da Lei 11.343/2006 não se mostra apta a configurar reincidência ou maus antecedentes, como já se decidiu:

"DISPARO DE ARMA DE FOGO - Denúncia acolhida integralmente - Recurso da defesa buscando a adoção do regime aberto - Alegação de que o art. 28, caput, da Lei 11.343/06 não gera antecedentes criminais - Apelo parcialmente acolhido - Penas que merecem readequação - Condenações pretéritas por porte de droga para uso pessoal que não geram maus antecedentes, conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça - Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão - Readequação da pena - Inexistência de motivos para alteração de regime de cumprimento de pena - Aplicação da Súmula nº 269, do col. Superior Tribunal de Justiça - Possibilidade de substituição da pena carcerária por restritiva de direitos por não se tratar de réu reincidente específico - Inteligência do § 3º do artigo 44 do CP - Recurso defensivo provido em parte." (TJSP; Apelação Criminal 0000431-21.2016.8.26.0213; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/05/2021; Data de Registro: 27/05/2021).

Assim sendo, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário, tendo em vista a ausência de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado.

Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Não há causas especiais de aumento de pena a serem apreciadas; presente, contudo, a

causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porque primário, não portador de maus antecedentes e ausentes provas de dedicação a atividade criminosa ou vinculação a organização criminosa; por isso, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes, cumpre reduzir a pena em 1/2.

Torno definitivo o quantum da pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Quanto ao delito do artigo 12 da Lei 10.826/03.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que se trata de réu que não ostenta maus antecedentes.

Com efeito, a condenação no artigo 28 da Lei 11.343/2006 não se mostra apta a configurar reincidência ou maus antecedentes, como já se decidiu:

"DISPARO DE ARMA DE FOGO - Denúncia acolhida integralmente - Recurso da defesa buscando a adoção do regime aberto - Alegação de que o art. 28, caput, da Lei 11.343/06 não gera antecedentes criminais - Apelo parcialmente acolhido - Penas que merecem readequação - Condenações pretéritas por porte de droga para uso pessoal que não geram maus antecedentes, conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça - Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão - Readequação da pena - Inexistência de motivos para alteração de regime de cumprimento de pena - Aplicação da Súmula nº 269, do col. Superior Tribunal de Justiça - Possibilidade de substituição da pena carcerária por restritiva de direitos por não se tratar de réu reincidente específico - Inteligência do § 3º do artigo 44 do CP - Recurso defensivo provido em parte." (TJSP; Apelação Criminal 0000431-21.2016.8.26.0213; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/05/2021; Data de Registro: 27/05/2021).

Assim sendo, fixa-se a pena-base em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, tendo em vista a ausência de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado.

Não há agravantes a considerar. Presente a atenuante da confissão. Todavia, deixo de reduzir a reprimenda, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e esta circunstância não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo previsto em lei, segundo dispõe a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas especiais de aumento e diminuição de pena a serem apreciadas.

Torno definitivo o quantum da pena.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas privativas de liberdade, totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção.

A hipótese dos autos se enquadra no decidido nos autos do HABEAS CORPUS Nº 596.603-SP, de modo que, tratando-se de tráfico privilegiado e considerando a quantidade de pena aplicada, fixa-se o regime aberto para início de cumprimento da pena.

Presentes os requisitos legais elencados no artigo 44, I a III do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, a ser definida pelo Juízo das Execuções, e por uma multa, consistente no pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, sem prejuízo da pena pecuniária original.

III. Dispositivo.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, julgo procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o réu LUIS HENRIQUE FIORAVANTE, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção (substituídas por prestação de serviços à comunidade e dez dias-multa) e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando suspensa a execução por ser o acusado beneficiário da Justiça Gratuita, benefício que ora lhe defiro. Anote-se.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista a pena fixada, autorizo o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Não comprovada a origem lícita, decreto o perdimento da quantia apreendida em favor da União, nos moldes do artigo 63, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Encaminhe-se a munição apreendida para destruição, providenciando-se o necessário.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.I.C.

Jardinópolis, 18 de fevereiro de 2022.

Joice Sofiati Salgado
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA